

1501426-79.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2193341/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 2193341 - 03º D.P. DIADEMA, 2396/21/127 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Clayton Feitoza Tavares de Moraes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501426-79.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501426-79.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2193341/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 2193341 - 03º D.P. DIADEMA, 2396/21/127 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Clayton Feitoza Tavares de Moraes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

VISTOS.

CLAYTON FEITOZA TAVARES DE MORAIS, qualificado às fls. 11 e 18/20, está sendo processado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 17 de julho de 2021, por volta das 11h15, na Rua Vereador Rubens de Oliveira, altura do nº 240, Piraporinha, nesta cidade de Diadema, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 30 embalagens plásticas contendo 21,19g da droga cocaína, 20 embalagens plásticas contendo 10,75g da mesma droga, na forma de crack, e 90 embalagens plásticas contendo 124g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 22/23 e laudo de constatação provisória de fls. 25/28, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl.46/49), a denúncia foi recebida em 18/10/21 (fl.158), sem proposta de transação penal, seguiu-se com a notificação e citação (fl.139), quem ofertou defesa inicial as fls.151/153, através de Advogada constituída, e devidamente intimada, não compareceu a audiência virtual nem respondeu aos chamados, não justificou ausência nem pleiteou adiamento, sendo nomeado Advogado Ad Hoc.

Em audiência una foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas Partes, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal diante da excessiva quantidade e variedade de drogas, sem possibilidade de substituição da pena e sim sua redução no mínimo legal, a qual ainda, deverá ser cumprida em regime fechado, sem possibilidade de apelo em liberdade, e sim com a perda do dinheiro e demais bens.

Já o d. Advogado Ad Hoc pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, fixando-se regime mais brando e substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, com direito de apelo em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem no auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, laudo de constatação e definitivo, ambos positivos para as drogas maconha e cocaína (respectivamente às fls. 25/28 e 108/110). Tem-se, ainda, os laudos com fotos do veículo onde as drogas estavam guardadas, bem como das anotações da contabilidade do tráfico e dos rádios e aparelho de som apreendidos (fls. 111/112 e 127/128).

A autoria é inconteste conforme prova que sigo analisando.

Os policiais militares afirmaram em solo pré-processual (fls. 07/10) que efetuavam patrulhamento preventivo quando foram acionados via COPOM para averiguarem ocorrência de tráfico de drogas praticado por 02 indivíduos, um de prenome William e o outro de prenome Clayton, que trajava um moletom azul e branco, que armazenavam as drogas no interior do veículo marca Peugeot, de cor cinza, estacionado no interior do condomínio da CDHU, situado no numeral 270 da Rua Vereador Rubens de Oliveira, Bairro Piraporinha, Diadema/SP. Deslocaram-se para o local apontado, avistaram o veículo Peugeot/206, placa DAQ-6358, cor cinza, e encostado a este automóvel estava um indivíduo trajando um moletom azul e branco. Abordado o indivíduo, posteriormente identificado CLAYTON FEITOZA TAVARES DE MORAIS, e procedida a busca pessoal, localizaram no bolso de sua calça uma chave de um automóvel. Indagado informalmente sobre aquela chave automotiva, o réu afirmou que

era da sua casa. Acionaram os botões existentes na chave automotiva, a qual destravou as portas e o alarme do veículo Peugeot/206. Procederam a busca veicular no interior do veículo e localizaram no assoalho do banco do passageiro uma sacola plástica contendo 90 tabletes de erva esverdeada com características de Maconha, 30 invólucros plásticos contendo substância em pó branca com características de Cocaína, 20 Invólucros plásticos contendo pedras amareladas com características de Crack. Sobre o banco do passageiro dianteiro localizaram 02 rádios comunicadores, tipo HT. No interior do porta-luvas localizaram a quantia de R\$ 129,00 e 01 folha contendo anotações típicas de contabilidade de tráfico de drogas. No banco traseiro foram localizados dois rádios automotivos e um fone de ouvido. Indagado informalmente as substâncias entorpecentes, numerário e demais objetos localizados no interior do veículo que o indiciado tinha inclusive a chave, ele afirmou que aquelas drogas não eram dele, não fornecendo maiores detalhes.

Em juízo o policial Marcos Camilo reiterou que o Copom pagou ocorrência de tráfico por dois indivíduos, Clayton e William, suas vestes e demais características, que estariam próximos a um veículo Peugeot prata e dentro deste estavam as drogas. Localizaram o réu perto do carro e com ele, dentro do bolso da calça, uma chave que acionou o alarme do carro e então ele alegou que um amigo havia deixado a chave com ele. Dentro do automóvel estavam os entorpecentes, um papel da contabilidade, rádio comunicador e dinheiro. Questionado, negou ser dele. O local era um ponto de venda de drogas já conhecido, mas não tinha visto o réu lá antes. Segundo relato dele, tinha um desafeto que deixara a chave do carro consigo. Mas sentiu um certo nervosismo por parte dele. E a denúncia foi muito detalhada e bateram as características. O réu disse não saber quem era William, cujo nome também constava na denúncia.

O policial Adalberto de Carvalho também reiterou que houve uma denúncia e ao chegarem no local o réu estava com as vestes e tinha as características passadas como sendo de uma das pessoas chamadas Wilson e Clayton, que eram os traficantes da região. No bolso da calça do réu havia uma chave que abriu o carro que estava bem próximo dele. Dentro do automóvel tinha drogas, dinheiro, papel com anotações típicas do tráfico e dois rádios comunicadores tipo walk talk. Reconhece o réu, quem negou ser dele tudo o encontrado, e não dava mais explicações. E já no DP disse que fora uma vingança de alguém que tinha deixado a chave com ele, e não indicou quem seria essa pessoa nem onde podia ser encontrada.

A testemunha de defesa Edenilson Rosa, não presenciou os fatos porque estava trabalhando. O réu já trabalhou consigo em construção civil e nunca tiveram problemas.

O réu, extrajudicialmente (fl.11), respondeu que foi chamado por um desafeto para conversar e que este, no intuito de prejudicar, lhe entregou as chaves do veículo Peugeot e realizou uma denúncia.

Sob o crivo do contraditório o acusado alegou que ia à padaria comprar pão e se encontrou com William, quem disse que dois motoqueiros viriam pegar algo e como demoravam, pediu para ele ficar com a chave e esperar, pagando-lhe cinquenta reais. Logo após veio uma viatura e lhe abordou. Como não sabia o que tinha dentro do carro, não correu. Foi abordado e não falou nada sobre saber que devia ter coisa errada no carro porque o William mexia com coisa errada, e sabia que tinha algo errado no carro, e esse foi seu erro. Questionado sobre as duas versões diversas que deu, respondeu que acabou segurando por medo de represália, retaliação. Tem três filhos para sustentar, tendo que pagar duas pensões alimentícias, e sua filha caçula mora consigo. Questionado pelo Advogado AdHoc, respondeu que conhece o William e nunca o viu com carro e achava que nem era dele.

Logo, os depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com

os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, tudo a confirmar a denúncia anônima que se mostrou verdadeira. Até porque nem o réu nem a Defesa lograram êxito em comprovar que um desafeto teria "armado" para "ferrar" com o réu, quem justamente não deveria ter aceitado a chave de um carro vindo justamente de seu inimigo. Tanto que nesta audiência ele trouxe outra versão completamente diversa, qual seja, de que conhece o William, cujo nome também constou na denúncia anônima, e que foi ele quem lhe entregou a chave do carro pagando-lhe cinquenta reais para esperar o motoqueiro Sandro a quem entregaria a chave de um carro, sabendo que tinha algo errado porque aquela citada pessoa mexe com coisas ilícitas. Mas não fez prova de nenhuma das duas histórias que narrou. Inclusive, não procede sua tese prestada hoje de que acatou o delito por medo de represálias por parte de William, hoje ele o delatou, o que demonstra contradição. Ao passo que a denúncia anônima foi específica e detalhada, e como visto, restou ser verdadeira. Ainda que em poder do réu não tenha sido localizada as drogas, anotações e etc..., pois em poder dele estava a chave do carro dentro do qual estavam as substâncias entorpecentes e demais bens ligados à traficância, ciente de que se tratavam de coisas ilícitas, embora alegue desconhecer que seriam, especificamente, drogas. Mas não provou.

Não bastasse isso, e mesmo que se tenha à fundamentar a condenação nos relatos dos milicianos, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos deles. E a defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ora, o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, se age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0), o que inócorre nesses autos.

No mais, e ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares ter em depósito e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

E em que pese o réu alegar ter filhos para sustentar e que de algum modo precisava de dinheiro, não há que se falar em situação de pobreza, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. (...) A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 70), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, mas por outro lado a excessiva quantidade de narcótico apreendido (140 invólucros no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo, qual seja, 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem consideradas, restando inalterada a pena nesta etapa. Nem se alegue que o réu tenha confessado o crime, pois ele trouxe várias versões e não provou nenhuma delas, tendo respondido ao d. Defensor que negava o tráfico a si imputado nesses autos.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu, faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls. 78), mas considerando os tipos de drogas, especialmente a cocaína e o crack, de alto poder nocivo e viciante, além da apreensão de dinheiro (fl. 72) e anotações da contabilidade do tráfico (fl. 22/23), tudo a indicar maior envolvimento o réu com a mercancia ilícita, opto pelo percentual de redução de 1/2, perfazendo 02 anos e 09 meses de reclusão e 275 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Incabível a benesse do art. 44 do CP ao réu diante da excessiva quantidade de substâncias entorpecentes e maior envolvimento do agente com o tráfico a indicar que não se mostra socialmente recomendável a substituição de sua pena corporal por restritivas de direitos, tratando-se de ação de extrema gravidade, sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade até pelo elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem da prática de delitos que tais, um verdadeiro meio de vida.

Some-se a isso o fato de que : ... O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves

Fixo o regime prisional semiaberto, diante de todo o exposto antes, e por conta da grande quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas. Segundo entendimento do STJ já firmado, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação

do regime prisional deve observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e da quantidade da droga. Assim, pode-se fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar tais circunstâncias, no caso desses autos 140 invólucros entre maconha, cocaína e crack, e por isso opto pelo regime intermediário. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o réu, ora condenado a regime que o manterá preso para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de três meses, e sem direito sequer à progressão de regime, considerando a prisão do réu por menos de seis meses.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória, consoante estabelecido pela Resolução n.º 113, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado. Mas decreto a perda do dinheiro e demais objetos apreendidos por serem provenientes do crime.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra CLAYTON FEITOZA TAVARES DE MORAIS, qualificado às fls. 11 e 18/20, como incurso no artigo 33 “caput” da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 275 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à

data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, em 100 UFESPS ante a constituição de Advogada particular, sem juntada de declaração de hipossuficiência até a presente data. E como esta não compareceu a audiência, embora devidamente intimada, foi nomeado Advogado Ad Hoc e pela Tabela de Honorários, Cód. 301, fixo o valor de R\$ 500,00 a serem pagos ao Dr. Lúcio.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 72/73), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de objetos apreendidos e de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias e em 60 dias as custas e honorários, sob as penas da lei.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA